

1502205-13.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

A ré, quando da prisão em flagrante, confessou que estava trabalhando no tráfico havia três meses a fim de sustentar seus cinco filhos.

Em juízo, em resumo, admitiu que traficava há uns três meses para sustentar seus filhos; negou que estivesse com drogas quando foi abordada pelos guardas na rua, ao quais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1502205-13.2021.8.26.0544Fls. de

Aos 6 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

ADALGIZA APARECIDA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 09h00, na Rua Plácido Panachi, na altura do numeral 315, e na Travessa José Papik, número 15, ambas no Parque San Francisco, nesta cidade comarca, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, 39 porções de maconha, 91 de cocaína e 374 de crack, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, a ré demonstrou nervosismo ao ver os guardas municipais em local tido como ponto de venda de drogas, sendo abordada e localizadas em seu poder 26 porções de cocaína e 13 de crack. Inquirida, a ré admitiu que abastecia os pontos de drogas e que guardava drogas em sua casa, onde os guardas acharam mais porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro e anotações sobre o tráfico.

Colocada em liberdade na audiência de custódia, notificada e citada a ré (fls. 169), pelo defensor foi apresentada defesa prévia (fls. 224/225 e 229/236), sendo recebida a denúncia (fls. 237/240).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais, de duas testemunhas de defesa e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 322/324), ao passo que a Defesa, em essência, pediu o reconhecimento de condições favoráveis na aplicação da pena (fls. 328/341).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Procede a ação penal.

A materialidade delitiva vem estampada nos laudos de constatação (fls. 28/34) e de exame químico-toxicológico (fls. 133/135) que resultaram positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, resultou certa a autoria, bem como a destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

A ré, quando da prisão em flagrante, confessou que estava trabalhando no tráfico havia três meses a fim de sustentar seus cinco filhos.

Em juízo, em resumo, admitiu que traficava há uns três meses para sustentar seus filhos; negou que estivesse com drogas quando foi abordada pelos guardas na rua, ao quais não lhe mostraram mandado de busca quando falaram que iriam ingressar na sua casa e acharam uma bolsa sobre a mesa na qual lhes disse que havia drogas.

A par da confissão da ré, os guardas municipais, em depoimentos seguros e concatenados, narraram que patrulhavam local conhecido pela prática do tráfico e resolveram abordar a ré porque mostrou nervosismo ante a presença das viaturas, sendo encontradas em seu poder 26 porções de cocaína e 13 de crack. Indagada, ela admitiu que trabalhava para o tráfico e abastecia as biqueiras do bairro e permitiu a realização de buscas na sua casa onde disse que havia mais drogas.

O GM J Souza relatou que a ré tinha drogas em seu poder, admitiu que abastecia as biqueiras e tinha mais drogas em sua casa, autorizando ingresso para avisar seu irmão para cuidar de seus filhos, onde acharam mas drogas.

O GM Correia disse que a ré, depois de encontradas drogas em seu poder, admitiu que trabalhava no tráfico e que tinha mais drogas em sua casa, as quais foram apreendidas junto com um caderno com anotações sobre o tráfico.

A testemunha Denise disse que nada presenciou porque estava trabalhando, mas sua filha disse que viu a ré ser abordada em frente de sua casa.

A testemunha Carmen disse que sendo vizinha viu os guardas entrando na casa da ré e a levando presa. Disse que ela cuida de cinco filhos menores e faz bicos, desconhecendo seu envolvimento no tráfico.

Diante deste quadro, gizado pela confissão corroborada pela prova vocal, dúvidas não há de que a ré tinha drogas consigo e em sua casa a fim de entregar ao consumo de terceiros.

Por fim, ao revés do alegado pela defesa, conquanto não se descure que não raras vezes há excesso na atuação dos guardas municipais, tanto havia fundadas razões para a abordagem que com a ré foram achadas drogas.

E não houve invasão de domicílio, mas pronta atuação dos guardas para checar a informação dada pela própria ré de que guardava drogas em sua casa, sendo

apreendida bolsa com significativa quantidade de drogas.

Vale dizer, a busca residencial não está maculada de qualquer vício, uma vez que se trata de situação de flagrante permanente justamente porque a ré armazenava as drogas em sua residência.

Não há, nesta toada, que se falar em ilicitude da prova, enfatizando que, conquanto não se olvide que não raro a Guarda Municipal exorbite sua atribuição legal de vigilância de bens, serviços e instalações públicas municipais, usurpando competência constitucional das polícias civil e militar, diligenciando, investigando e reprimindo condutas, excedendo seu escopo institucional de agente auxiliar e de cooperação com as forças de segurança pública, tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito permanente, que se prolonga no tempo, a detenção de indivíduo praticando uma das dezoito condutas nucleares do tipo autoriza a prisão em flagrante, na forma do artigo 301 do CPP. A propósito:

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Conduta desclassificada para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Recursos do Ministério Público e da defesa técnica - Defesa sustenta a nulidade do feito, diante da atuação ilegal da guarda civil na prisão em flagrante e apreensão das drogas - Não há que se falar em prova ilícita, porquanto a atuação da guarda civil se limitou a checar a veracidade de delação anônima, não se verificando atos típicos de investigação policial - Mérito - Acusação pede a condenação pelo crime de tráfico de drogas - Pouca quantidade de drogas, sem provas da prática de atos mercantis - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500530-78.2020.8.26.0599; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 05/10/2021).

Passo à fixação da pena.

Ponderadas as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando que embora seja a ré primária e sem antecedentes criminais, a quantidade de drogas apreendidas indica que visava suprir grande número de desgraçados usuários, fixo a pena-base um quinto acima do patamar mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

Dada a confissão espontânea, reduzo a pena em igual montante na segunda fase, retornando ao patamar mínimo.

Sendo a ré primária, sem antecedentes e não havendo prova de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, mas observada a quantidade de droga, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em metade, tornando-a definitiva em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta e dias-multa.

Como ensina Guilherme de Souza Nucci: "(...) se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como a pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição da pena (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base (a primeira etapa da aplicação da pena, conforme artigo 68 do Código Penal). O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para utilização na diminuição da pena (ex.: um sexto)." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 330).

Sem parâmetros para melhor análise da situação econômica da ré, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo

vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 43 da Lei de Drogas.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais da ré, mãe de cinco filhos menores, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal.

Assim é porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006 que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 33, parágrafo 4º, e artigo 44, parte final) para condenado por crime de tráfico ilícito de drogas (HC 97256-RS, Pleno, relator Ministro Ayres Britto, julgado em 26/08/2010).

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal por ser a acusada primária, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, reduzida a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda imposta.

O moderno entendimento dos tribunais superiores caminha no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ADALGIZA APARECIDA SILVA, qualificada nos autos, à pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, e à pena pecuniária de duzentos e cinquenta dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Ante a conversão em penas alternativas poderá a ré recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenada, a ré arcará com as custas processuais, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, intime-se para cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 6 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 6 de julho de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: